

同导致行为的手段、需要提供的证件、办理的手续上均存在差异，在是否有偷渡入境情节上也 有着关键的区分。从法益保护的角度来看，组织他人偷越国(边)境罪侵犯的是 国家对进出国(边)境的管理制度，而出售出入境证件罪侵犯的是国家对出入境 证件的管理秩序，两者侵犯了不同法益。本案中，根据是为境外外籍人员提供非法入境服务还是为境内外籍人员提供非法居留服务等情况，将包某某的行为区分为组织他人偷越国(边)境行为和出售出入境证件行为，在行为对象上不存在重叠交叉，也不存在重复评价需要择一重罪论处的问题，故依法应数罪并罚。但考虑两者在行为手段上存在一定的相似性，在量刑时可酌情从轻考虑。

编写人：上海市松江区人民法院 胡晓晖 钱莹 韩玲

(四)危害公共卫生罪

36

刑满释放后再次非法行医且未造成实害后果和 危险的亦应适用“其他情节严重情形”

——陈某某非法行医案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省宿迁市中级人民法院(2022)苏13刑终117号刑事裁定书

2. 案由：非法行医罪

【基本案情】

被告人陈某某曾在2013年8月7日、2014年9月16日因在未取得《医师资格证书》《医师执业证书》《医疗机构执业许可证》的情况下擅自开展诊疗活动，两次被给予行政处罚。后因再次非法行医，于2018年1月11日被江苏省宿迁市宿豫区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元。2018年7月24日，被告人陈某某刑满释放。2020年9月1日，被告人陈某某又在未取得《医师资格证书》《医师执业证书》《医疗机构执业许可证》的情况下，明知自己不具备行医资格，仍在某地擅自非法开展针灸诊疗活动，被宿迁市卫生健康委员会当场查获。宿迁市卫生健康委员会以陈某某涉嫌非法行医犯罪而移送公安机关。

【案件焦点】

1. 仅查到一次诊治行为能否认定被告人陈某某实施非法行医行为；2. 被告人的行为是否应适用非法行医罪司法解释规定的“其他情节严重情形”。

【法院裁判要旨】

江苏省宿迁市宿豫区人民法院经审理认为：被告人陈某某在未取得医生执业资格的情况下，非法从事医疗活动，情节严重，其行为构成非法行医罪。被告人陈某某自动投案，在归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百三十六条第一款、第六十七条第一款、第六十五条以及《最高人民法院〈关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条之规定，判决：

一、被告人陈某某犯非法行医罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；

二、将扣押的针12支，予以没收，由扣押机关依法处理。宣判后，被告人陈某某提出上诉。

江苏省宿迁市中级人民法院经审理认为：上诉人陈某某在未取得医生执业资格的情况下，非法从事医疗活动，情节严重，其行为已构成非法行医罪。上诉人陈某某自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。上诉人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。原审法院认定上诉人陈某某犯非法行医罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。江苏省宿迁市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见正确，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

利益驱使或是谋生需要，部分行为人在因非法行医被刑事处罚后仍会继续非法行医，且方法会更加隐蔽，如未有门头、在雇用有执业资格的医生坐诊时穿插问诊、开处方不标注姓名、当日单据当日销毁等，加大了非法行医的查处难度。当未出现实害后果时，卫生监督部门可能仅能查实当日或当时的行为，也就是说查实行为人诊治次数较少，甚至只有一次，我们首要界定行为人的行为是否为非法行医，再评判行为是否达到“情节严重”及适用情形，从而准确入罪追责。

一、被告人陈某某实施的针灸行为系诊疗活动，属于法律规定的非法行医

根据《最高人民法院关于审理非法行医刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，非法行医主要指未取得、非法取得、已取得被吊销或超范围从事医疗活动或医疗行为。因此，准确界定医疗活动或者医疗行为的内涵是认定非法行医的关键。本罪司法解释并未对“医疗活动”“医疗行为”的内涵作出解释，而是参照《医疗机构管理条例实施细则》中对“诊疗活动”“医疗美容”的认定。《医疗机构管理条例实施细则》第八十八条规定，诊疗活动，是

指通过各种检查,使用药物、器械及手术等方法,对疾病作出判断和消除疾病、缓解病情、减轻痛苦、改善功能、延长生命、帮助患者恢复健康的活动。从条款字面意思角度分析,诊疗活动是执业医师运用有效方法对病人所患疾病作出诊断并以此给予诊疗方案,达到帮助病人消除疾病、缓解病情、恢复健康等活动,并未要求以对多人或多次实施行医行为作为认定诊疗活动的限制条件。简言之,只要行为人对病人进行诊断,给出治疗方案,利于病人减缓病痛或恢复健康的行为,就是诊疗活动。当非法医疗行为未造成实害后果时,非法行医行为一般以行政处罚方式予以监督管理,且《医疗机构管理条例实施细则》关于非法行医被行政处罚内容,也未以人数、次数为限制条件,如发现未取得资格证擅自执业的即被行政处罚等。此种理解不会出现刑事手段打击范围过宽的情形。因立法者在立法时已考虑实践情况,增加了“情节严重”的限制条件,为行政处罚留有相应空间。

就本案而言,2020年9月1日,被告人陈某某知道自己不具备行医资格,仍在某地家中为侍某诊断病情,并进行针灸治疗,缓解侍某的病痛,符合医疗活动特征,属于非法行医行为。

二、被告人陈某某在刑满释放后再次实施非法行医行为,属于该罪的“其他情节严重”情形

非法行医罪的入罪条件之一情节严重,立法者采取“列举+兜底条款”的方式,从实害后果、对公共卫生的危害程度、行为人的主观恶性等方面对“情节严重”情形予以例举,并以兜底条款来应对情势变化和法律疏漏。一般而言,我们都以同质解释方法对兜底条款作出合理解释,达到恰当适用刑法惩治手段的目的。也就是说,对于列举情节严重之外的非法行医行为是否属于其他情节严重,我们应从行为违法性和社会危害性上予以评判,只有与明确列举的情节严重情形的社会危害性相当,才具有刑事可罚性。非法行医罪的“其他严重情节情形”亦在此范畴。同时,非法行医罪的“其他严重情节情形”没有明确具体内容,我们亦可用“举轻以明重”的原则比较相应行为的社会危害性,若重行为的危害性大于轻行为,则可入罪,反之出罪。

本案中，被告人陈某某曾在2013年8月7日、2014年9月16日因非法行医，先后两次被给予行政处罚。后因再次非法行医，于2018年1月11日被宿迁市宿豫区人民法院判处刑罚，刑满释放后，于2020年9月1日因非法行医被查处。上述情形与非法行医罪的情节严重情形之一的“非法行医被卫生行政部门行政处罚两次以后，再次非法行医的”相似，二者是在未出现实害后果、对公共卫生、人身造成危险的前提下相比较，具有合理性。从主观上看，因非法行医两次行政处罚后再次行政处罚的主观恶性，与因非法行医受到刑事处罚后又实施非法行医行为的主观恶性相比，后者明显重于前者；从行为情节上看，因非法行医被两次行政处罚，在第三次非法行医被查处，予以刑事追责，较犯非法行医罪刑满释放后又因非法行医被查处，刑事处罚明显重于两次行政处罚，后者的刑事处罚相当于有三次行政处罚，从处罚次数上也比前者重，行为的危害性更大，被告人的人身危险性更大，具有刑罚处罚性。从现场勘查笔录、现场照片看，上诉人陈某某在其居住处为他人从事非法医疗活动，场所内无任何医疗设备、药品用于应对突发情况，也不具备从事医疗活动条件，给患者带来隐患。因此，本案认定被告人陈某某的行为属于非法行医罪的“其他情节严重”情形；予以入罪追责，符合法律规定。

总之，刑法的谦抑性和严厉性，要求我们适用刑法时要慎重。在法律无明确规定，质疑相关行为能否入罪时，我们应从本罪构成要件出发，提炼法律明确列举情形的关键特征，准确运用法律方法解释法律条文含义，甄别行为性质，达到准确适用法律的目的。

编写人：江苏省宿迁市中级人民法院 白金